

**RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK**

**VOORZITTER VAN DE XIIe KAMER**

**A R R E S T**

**nr. 241.171 van 29 maart 2018  
in de zaak A. 224.720/XII-8516**

In zake: de NV KAPSCH PUBLICTRANSPORTCOM BELGIUM  
bijgestaan en vertegenwoordigd door  
advocaten William Timmermans en Julien Gaul  
kantoor houdend te 1000 Brussel  
Havenlaan 86 C/414  
bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

de VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN  
bijgestaan en vertegenwoordigd door  
advocaten Jens Debièvre en Yasmine D’hanis  
kantoor houdend te 1000 Brussel  
Havenlaan 86c  
bij wie woonplaats wordt gekozen

Tussenkomende partij:

de BV PST GOSMART  
bijgestaan en vertegenwoordigd door  
advocaten Philip Peerens en Sébastien Elst  
kantoor houdend te 1170 Brussel  
Terhulpssteenweg 166  
bij wie woonplaats wordt gekozen

---

*I. Voorwerp van de vordering*

1. De vordering, ingesteld op 8 maart 2018, strekt tot de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van “de gunningsbeslissing van 21 februari 2018 van [de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn] voor de opdracht voor levering van ReTiBo onderdelen voor de installatie

op nieuwe voertuigen (Techn\_Rollend Materieel-2017-mibjd-243) wat perceel 1 van die opdracht betreft.”

## *II. Verloop van de rechtspleging*

2. De verwerende partij heeft een nota ingediend.

Met een verzoekschrift van 15 maart 2018 heeft de bv PST goSmart gevraagd om in het administratief kort geding te mogen tussenkomen.

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 20 maart 2018, om 10.00 uur.

Kamervoorzitter Dierk Verbiest heeft verslag uitgebracht.

Advocaten William Timmermans en Julien Gaul, die verschijnen voor de verzoekende partij, advocaat Yasmine D’hanis, die verschijnt voor de verwerende partij, en advocaat Philip Peerens, die verschijnt voor de tussenkomende partij, zijn gehoord.

Auditeur Ines Martens heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

## *III. Feiten*

3.1. De Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn schrijft een overheidsopdracht uit voor de levering van ReTiBo-onderdelen voor nieuwe voertuigen. Het betreft een raamovereenkomst voor 4 jaar, tweemaal verlengbaar met twee jaar.

De opdracht is onderverdeeld in drie percelen, waarbij de voorliggende vordering enkel perceel 1 betreft: “ReTiBo specifieke toebehoren, vb. montageset voor een ReTiBo validator”. ReTiBo staat voor Registratie-, Ticketing- en Boordcomputer.

De opdracht wordt gegund met een openbare procedure met één gunningscriterium, de prijs.

3.2. De opdracht wordt bekendgemaakt in het Bulletin der Aanbestedingen op 13 december 2017 en in het Supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie op 16 december 2017.

3.3. De opdracht is onderworpen aan het bijzonder bestek “Levering ReTiBo onderdelen voor de installatie op nieuwe voertuigen / Techn\_Rollend Materieel – 2017-mibjd-243”.

In het bestek wordt met betrekking tot de selectie van de inschrijvers onder meer bepaald:

“1.04. Selectie van de inschrijvers: Uitsluitingsgronden & Kwalitatieve selectie

1.04.1 Algemene Bepalingen

De aanbestedende entiteit gaat over tot de selectie van de inschrijvers in de mate dat de noodzakelijke inlichtingen en documenten aantonen dat ze cumulatief voldoen aan:

- De bepalingen betreffende de uitsluitingsgronden zoals verder bepaald;
- De selectiecriteria zoals verder bepaald.

Enkel de offertes die voldoen aan de selectiecriteria en regelmatig zijn, zullen worden getoetst aan de gunningscriteria.

[...]

1.04.6 Selectiecriteria (art. 70 e.v. KB Plaatsing)

De aanbestedende entiteit zal zelf de vereiste selectiecriteria bepalen. De artikelen 65 tot en met 69 en 72 van het KB plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017 zijn dan ook niet van toepassing. Voor perceel 1:

Minstens twee referenties van leveringen van boordcomputer- en of ticketing-gerelateerde apparatuur aan openbare vervoermaatschappijen.”

3.4. Op 25 januari 2018 vindt de openingszitting plaats. Twee inschrijvers dienen een offerte in voor perceel 1, namelijk de verzoekende partij, voorheen de nv Kapsch CarrierCom Belgium en de eerste gerangschikte inschrijver, de bv PST goSmart.

3.5. Wat het onderzoek van de selectievereisten met betrekking tot perceel 1 betreft, wordt in het gunningsverslag vermeld dat bij iedere inschrijver werd gecontroleerd of de door hem ingediende offerte voldeed aan de selectie- en minimumvereisten alsook aan de technische vereisten van het bestek en de hier in het geding zijnde inschrijvers een regelmatige offerte hebben ingediend.

3.6. Op 21 februari 2018 beslist de raad van bestuur van De Lijn om de raamovereenkomst voor de levering van ReTiBo-onderdelen voor de installatie op nieuwe voertuigen voor vier jaar, tweemaal verlengbaar met twee jaar, te gunnen als volgt:

“Perceel 1: bv PST goSmart en Kapsch CarrierCom Belgium. De best gerangschikte, zijnde bv PST goSmart, mag starten met de uitvoering van de opdracht voor een periode van vier jaar, jaarlijks opzegbaar volgens het evaluatiesysteem, tweemaal verlengbaar met twee jaar voor het bedrag van 3.238.423, 5 euro voor de hele looptijd van het contract.”

Dit is de bestreden beslissing.

3.7. Bij aangetekende brief van 21 februari 2018 worden de bestreden beslissing en het gunningsverslag meegedeeld aan de verzoekende partij.

3.8. Bij aangetekende brief en bij e-mailbericht van 28 februari 2018 vraagt de verzoekende partij aan de verwerende partij onder meer een kopie van de referenties die de bv PST goSmart bij haar offerte voegde. Bij e-mailbericht van 2 maart 2018 bezorgt de verwerende partij aan de verzoekende partij onder meer de gevraagde referenties.

#### IV. Tussenkoms

4. De bv PST Gosmart blijkt voordeel te halen uit de bestreden beslissing en heeft er belang bij dat de vordering wordt afgewezen. Bijgevolg moet haar verzoek tot tussenkoms worden ingewilligd.

#### V. Schorsingsvoorwaarden

5.1. Krachtens artikel 17, §§ 1 en 4, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan tot schorsing van de tenuitvoerlegging bij uiterst dringende noodzakelijkheid slechts worden besloten onder de dubbele voorwaarde dat minstens één ernstig middel wordt aangevoerd dat de nietigverklaring van de akte of het reglement *prima facie* kan verantwoorden en dat een uiterst dringende noodzakelijkheid voorhanden is die onverenigbaar is met de behandelingstermijn van de gewone vordering tot schorsing.

5.2. Te dezen is evenwel ook de wet van 17 juni 2013 ‘betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies’ van toepassing, zoals laatst gewijzigd bij de wet van 16 februari 2017.

Krachtens artikel 15, eerste lid, van die wet kan de uitvoering worden geschorst van de thans bestreden beslissing in aanwezigheid van een ernstig middel of een klaarblijkelijke onwettigheid.

Overeenkomstig artikel 15, tweede lid, echter wordt de vordering tot schorsing voor de Raad van State uitsluitend ingesteld volgens een procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid.

Er dient te dezen dan ook enkel nog te worden onderzocht of minstens één ernstig middel wordt aangevoerd, dan wel een klaarblijkelijke onwettigheid aanwezig is, die de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan verantwoorden.

## VI. Onderzoek van de middelen

### A. Eerste middel

#### *Uiteenzetting van het middel*

#### 6. De verzoekende partij betoogt:

“Het eerste middel is afgeleid uit de schending van ‘artikel 66 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, van de artikelen 70 e.v. van het koninklijk besluit van 18 juni 2017 Plaatsing Speciale Sectoren alsook van het bestek van verwerende partij, in het bijzonder van de bepaling inzake de selectie van de inschrijvers (besteksbepaling 1.04.6 Selectiecriteria; stuk A.3., bestek, pag. 13-14) en van het beginsel ‘*patere legem quam ipse fecisti*’ en van het gelijkheidsbeginsel’;

Doordat verwerende partij heeft beslist dat de door PST goSmart BV voor perceel 1 voorgelegde referenties voldoen aan de besteksvereisten en aldus deze inschrijver heeft geselecteerd en vervolgens als meest gunstig gerangschikte inschrijver heeft gekozen;

Terwijl de door PSTgoSmart BV voor perceel 1 voorgelegde referenties volstrekt niet voldoen aan de besteksvereisten aangezien de voorgelegde referenties geen ‘zowel inhoudelijk als omvang’ vergelijkbare opdrachten zijn, zodat de in het middel aangehaald beginselen geschonden zijn.”

De verzoekende partij voert in een toelichting bij dit middel concreet aan dat het bestek aan de inschrijvers oplegde om twee referenties voor te leggen van “leveringen van boordcomputer- en/of ticketing-gerelateerde apparatuur aan openbare vervoersmaatschappijen” die vergelijkbare opdrachten moeten zijn, “zowel inhoudelijk als qua omvang”. De verzoekende partij wijst daarbij in het bijzonder op het feit dat het gaat om “boordcomputer- en/of ticketing-gerelateerde apparatuur”. Het betreft aldus niet de validator zelf. Het betreft de montageonderdelen die vooraf worden geplaatst en waarop nadien de eigenlijke validator wordt geplaatst.

Wat het vereiste van inhoudelijke vergelijkbaarheid betreft, verwijst de verzoekende partij naar de beschrijving in het bestek van perceel 1. Zij besluit daaruit dat inhoudelijk gezien, onder meer essentiële onderdelen voor

perceel 1 zijn: montageonderdelen voor boordcomputer, voor “intelligente stroomvoorzieningselementen” en diverse montageonderdelen van consoles voor de bestuurder. Perceel 1 heeft geen betrekking op netwerkkapapparaat (perceel 2) en evenmin op datacenters of biometrische systemen. Voorts wijst de verzoekende partij er in het kader van de inhoudelijke vergelijkbaarheid op dat de plaatsing zowel op bussen als op trams zal gebeuren en dat het volgens het bestek om 1.000 bussen en 155 trams gaat.

De twee referenties die door de bv PST goSmart worden voorgelegd betreffen volgens de verzoekende partij enkel validatoren waarbij geen melding wordt gemaakt van montageonderdelen voor validatoren of boordcomputers of intelligente stroomvoorzieningselementen. Evenmin omvatten de referenties montageonderdelen van consoles voor de bestuurder. Het in de referenties vermelde datacenter, internettoegang en het biometrisch identificatiesysteem zijn in de in het geding zijnde opdracht niet relevant. Bovendien zijn de opdrachten qua aantallen niet te vergelijken met de in het geding zijnde opdracht aangezien in de referenties geen aantallen worden vermeld. De referenties hebben ook geen betrekking op trams. Uit de referenties blijkt geenszins dat de montageonderdelen deel uitmaken van deze referenties. Het gegeven dat deze referenties betrekking hebben op validatoren impliceert volgens de verzoekende partij geenszins dat ze ook automatisch betrekking hebben op de gerelateerde apparatuur. De verwerende partij organiseert immers zelf afzonderlijke opdrachten voor de validatoren, enerzijds, en de gerelateerde apparatuur, anderzijds.

De verzoekende partij stelt voorts dat uit de beschikbaar gestelde informatie niet blijkt dat de verwerende partij de referenties grondig heeft onderzocht.

### *Beoordeling*

7. Artikel 147, § 1, 2°, van de wet van 17 juni 2016 ‘inzake overheidsopdrachten 2016’ (hierna: wet overheidsopdrachten 2016) betreft de

overheidsopdrachten in de speciale sectoren en bepaalt dat de aanbestedende entiteit inschrijvers en kandidaten selecteert overeenkomstig de in de artikelen 149 en 151 vastgestelde objectieve regels en criteria. Luidens artikel 151, § 2, van de voormelde wet kunnen de criteria voor selectie van kandidaten en inschrijvers de in artikel 71 bedoelde selectiecriteria inhouden volgens de krachtens deze bepaling bepaalde voorwaarden. Met toepassing van het artikel 71, 3°, kunnen de selectiecriteria aldus betrekking hebben op de “technische en beroepsbekwaamheid”. Krachtens het tweede lid van dat artikel 71 beperkt de aanbestedende overheid deze criteria tot die welke kunnen garanderen dat een kandidaat of inschrijver onder meer over de technische bekwaamheden en beroepsbekwaamheden beschikt om de opdracht uit te voeren waarbij de voorwaarden verband houden met en in verhouding staan tot het voorwerp van de opdracht.

Te dezen werd in het bestek voor perceel 1 het volgend selectie-criterium bepaald:

“Minstens twee referenties van leveringen van boordcomputer- en of ticketing-gerelateerde apparatuur aan openbare vervoermaatschappijen.”

In deze omschrijving van het selectiecriterium wordt niet bepaald wat onder “boordcomputer- en/of ticketing- gerelateerde apparatuur” dient te worden begrepen. Het bestek schrijft daarbij wel voor dat het onder meer moet gaan om “vergelijkbare opdrachten zowel inhoudelijk als qua omvang”.

Wat de inhoud betreft van de opdracht voor perceel 1, kan worden verwezen naar de gedetailleerde omschrijving van de opdracht onder artikel 3.01 van het bestek, dat luidt:

#### “3.01 Doel en gedetailleerde omschrijving van de opdracht

Het doel van de opdracht is om De Lijn toe te laten nieuwe voertuigen uit te rusten met ReTiBo apparatuur. De ReTiBo apparatuur bestaat ondermeer uit validatoren die een MoBIB smart-card kunnen ‘lezen’, een chauffeurs-display die informatie verstrekt aan de chauffeur, een boordcomputer die ondermeer [instaat] voor de communicatie tussen de apparaten op het voertuig en een backend systeem, netwerk switches, acces points en antennes.

Vermits de meeste nieuwe voertuigen aangekocht worden ter vervanging van een ander voertuig kunnen de apparaten zoals validatoren, chauffeursdisplay en boordcomputer gerecupereerd worden uit het te vervangen voertuig. Maar de montageonderdelen en netwerkonderdelen zijn vaak niet recupereerbaar. Met deze opdracht is De Lijn in staat om deze montageonderdelen en netwerkonderdelen aan te kopen. In de meeste gevallen bezorgt De Lijn deze onderdelen, na ontvangst, aan voertuigfabrikanten zodat zij de onderdelen op de nieuwe voertuigen kunnen monteren.

Het bestek is opgedeeld in 3 percelen. Elk perceel heeft een aparte focus:

Perceel 1: ReTiBo specifieke toebehoren, bv montageset voor een ReTiBo validator

De montageonderdelen voor de ReTiBo apparaten zelf moeten specifiek op maat zijn voor de (bestaande) apparaten. De inschrijver garandeert conformiteit aan de originele ReTiBo montageonderdelen.

De specificaties van elk onderdeel zijn beschreven in bijlage TechSpec\_P1.pdf.

Indien de inschrijver vragen heeft over de specificaties kan hij die stellen via email, of indien hij een ReTiBo toestel of installatie fysisch wil zien, kan hij daarvoor via email een afspraak maken.

Perceel 1 bevat de volgende onderdelen:

[...]

Uit de voormelde omschrijving van het betrokken selectie-criterium in het bestek samen genomen met de omschrijving van het voorwerp van de opdracht blijkt op het eerste gezicht dat aan de kandidaten werd gevraagd om twee referenties voor te leggen van leveringen van boordcomputer- en/of ticketing-gerelateerde apparatuur, te weten de montageonderdelen voor een boordcomputer of een validator of andere ticketing-gerelateerde apparatuur aan openbare vervoermaatschappijen, zoals bijvoorbeeld een “montageset cradle boordcomputer”, “DC grondplaat”, “Kit montage validator” (bestek op de hiervoor aangehaalde bladzijde 33). Met de verwerende partij moet worden vastgesteld dat het in de eerste plaats aan haar toekomt om de voorgelegde referenties te beoordelen op hun overeenstemming met het gevraagde. De aanbestedende overheid beschikt terzake over een zekere beoordelingsvrijheid. Te dezen stelt zich daarbij de vraag of de aanbestedende overheid de grenzen van haar beoordelingsbevoegdheid geschonden heeft door aan te nemen dat de door de PST goSmart voorgelegde referenties voldeden aan het selectievereiste en dat de levering van montageonderdelen voor boordcomputer- en/of ticketing-gerelateerde apparatuur begrepen zit in de referenties die zij heeft

voorgelegd.

Met de verwerende partij lijkt op het eerste gezicht te moeten worden aangenomen dat het selectievereiste, dat het gaat om referenties voor ‘vergelijkbare’ opdrachten, niet inhoudt dat de referenties identiek dezelfde montageonderdelen moeten betreffen als degene die voor de in het geding zijnde opdracht zullen moeten worden geleverd. Zoals uit de hiervoor aangehaalde gedetailleerde omschrijving van de opdracht in de technische bepalingen van het bestek blijkt, zullen de gekozen inschrijvers montageonderdelen moeten leveren die specifiek op maat zijn voor de bestaande apparaten die door De Lijn uit de te vervangen voertuigen worden gerecupereerd. In de omschrijving van het selectievereiste wordt echter niet bepaald dat de kandidaten referenties moeten voorleggen van leveringen van montageonderdelen die identiek zijn aan de montageonderdelen die voor de opdracht op maat zullen moeten worden geleverd. Daargelaten de vraag of een dergelijk selectievereiste al dan niet op gespannen voet zou staan met de vrije mededinging en de gelijke behandeling van mogelijke kandidaten, zoals de verwerende partij doet gelden, moet worden vastgesteld dat een dergelijke voorwaarde op het eerste gezicht niet is opgenomen in de selectievereisten voor deze opdracht. Zoals de verwerende partij terecht aanvoert, betekent vergelijkbaar niet identiek.

Voorts dient te worden onderzocht of de door de bv PST goSmart voorgelegde referenties al dan niet de levering van montageonderdelen inhielden.

De door de bv PST goSmart aangeleverde referentie 1 betreft het “Assembleren, testen, leveren en installeren van AFC-apparatuur waaronder 1320 validators, inclusief modem en bijbehorende WLAN-antenne, 1320 biometrische lezers, 21 data collection points, 57 MIFARE kaartlezers, 360 externe online verkooppunten voor de verkoop van single tickets, met toetsenbord, display, printer en GSM/GPRS-modem”. De door de bv PST goSmart voorgelegde referentie 2 betreft het leveren en installeren van het ticketingsysteem en het

real-time controlesysteem waaronder 730 busvalidators, WIFI-communicatiemodule en GPS/GPRS modems, 620 biometrische lezers, 110 WIFI-routers aan boord van de voertuigen.

De verwerende partij en de tussenkommende partij betogen dat het leveren en installeren van de voormelde busvalidators en ticketing-apparatuur eveneens de levering impliceert van de montageonderdelen om deze apparatuur te bevestigen aangezien deze apparatuur niet los op de grond van de bus ligt. Bovendien wijst de verwerende partij er op dat de montageonderdelen specifiek zijn voor elk soort boordcomputers of validatoren, wat de stelling ondersteunt dat de apparatuur voor ticketing en validering en de montageonderdelen in de door de bv PST goSmart voorgelegde referenties samen werden geleverd.

Deze argumentatie van de verwerende partij en de tussenkommende partij wordt op het eerste gezicht ook ondersteund door foto's die door de verwerende partij bij haar nota zijn gevoegd.

Ten slotte wordt deze stelling versterkt door een verklaring van de Braziliaanse openbare vervoersmaatschappij voor wie de betrokken referenties werden uitgevoerd, die door de tussenkommende partij in het kader van de huidige schorsingsprocedure wordt bijgebracht. Uit deze verklaring blijkt dat voor de referentieopdrachten van de bv PST goSmart alle nodige installatie- en montageonderdelen werden geleverd zoals onder meer montageset, onderplaten en metalen ondersteuningsonderdelen.

Het gegeven dat de boordcomputer- en/of validatoren te dezen geen deel zouden uitmaken van de opdracht waardoor perceel 1 slechts de montageonderdelen betreft en niet de apparaten en de montageonderdelen van de apparaten samen, lijkt de stelling van de verwerende partij en de tussenkommende partij niet van haar geloofwaardigheid te ontdoen. Immers, bij de omschrijving van de opdracht in het bestek wordt de eigenheid van de opdracht uiteengezet, namelijk dat de aanbestedende overheid te dezen ervoor heeft geopteerd om apparaten zoals

de validator en de boordcomputer uit de te vervangen voertuigen te recupereren zodat enkel de montageonderdelen dienen te worden vervangen alsook de netwerkonderdelen, die aldus het voorwerp uitmaken van de in het geding zijnde opdracht.

De verzoekende partij toont ook niet aan dat het gangbaar zou zijn dat slechts de apparaten worden geleverd zonder de noodzakelijke montageonderdelen, hetgeen naar haar mening het geval is bij de door de bv PST goSmart voorgelegde referenties. In de door de verzoekende partij zelf voorgelegde referenties blijkt het overigens ook telkens te gaan om levering van apparatuur voor ticketing (validators, boordcomputers, ...) met inbegrip van de montageonderdelen. In die zin maakt de verzoekende partij niet aannemelijk dat een referentie voor de levering en de installatie van validators voor openbaar vervoer enkel de apparaten zou betreffen, maar niet de montageonderdelen of dat de levering en installatie van validators en dergelijke steeds afzonderlijk van de levering van de montageonderdelen gebeurt. Voorts toont de verzoekende partij niet concreet aan, en lijkt het voor de Raad van State niet mogelijk om zonder deskundige bijstand in de huidige stand van het geding haar stelling te beoordelen, dat de in de referenties van de bv PST goSmart eventueel opgenomen montageonderdelen in geen geval voldoende vergelijkbaar zijn met de montageonderdelen die voor de huidige opdracht dienen te worden geleverd. Hierbij moet in herinnering worden gebracht dat het vereiste van vergelijkbaarheid niet lijkt in te houden dat de onderdelen uit de referenties identiek zijn aan de onderdelen die zullen worden geleverd in het kader van de huidige opdracht.

8. Wat de bewering van de verzoekende partij betreft dat in de referenties die door de bv PST goSmart werden voorgelegd niet zou zijn aangegeven om welke aantallen het gaat, lijkt deze bewering niet te stroken met de feitelijke gegevens. Bij de beschrijving opgenomen in de referentiefiches wordt immers aangegeven hoeveel validators en dergelijke werden geleverd zodat zulks ook een indicatie geeft van de aantallen van montageonderdelen die voor de installatie ervan werden geleverd. De verwerende partij lijkt er ook terecht op te wijzen dat de verzoekende partij zelf evenmin in haar referenties specifieke

hoeveelheden heeft vermeld met betrekking tot de geleverde montageonderdelen.

9. Wat de opmerking van de verzoekende partij betreft dat door de bv PST goSmart geen enkele referentie inzake trams werd voorgelegd terwijl de in het geding zijnde opdracht zowel trams als bussen zal betreffen, kan de verwerende partij worden bijgevallen waar zij stelt dat in het selectievereiste niet werd bepaald dat de referentie zowel betrekking diende te hebben op trams als bussen. Bovendien wijst de verwerende partij er op dat de montageonderdelen dezelfde zijn voor bussen en trams, welke stelling in de huidige stand van het geding aannemelijk lijkt, zodat een referentie die enkel betrekking heeft op bussen voldoende vergelijkbaar lijkt. De relevantie van deze kritiek in het kader van de beoordeling van de technische bekwaamheid wordt dan ook niet aangetoond.

10. Het eerste middel is niet ernstig.

#### *B. Tweede middel*

##### *Uiteenzetting van het middel*

11. De verzoekende partij voert in een tweede middel de schending aan van de formelemotiveringsplicht zoals die onder meer is vervat in de artikelen 4, 8°, en artikel 5, 6°, juncto artikel 8, § 1, van de wet van 17 juni 2013 ‘betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies’ en in de wet van 29 juli 1991 ‘betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen’ en “van de verplichting dat die motivering voldoende draagkrachtig en afdoende moet zijn en van het zorgvuldigheidsbeginsel”.

Zij acht die formelemotiveringsverplichting geschonden:

“Doordat de bestreden beslissing geen enkele motivering bevat op grond waarvan besloten wordt dat de door PST goSmart bv aangevoerde referenties voldoen aan de besteksvereisten van de verwerende partij;

En doordat op geen enkele wijze wordt aangetoond dat de verwerende partij een zorgvuldig onderzoek heeft gevoerd naar de aanvaardbaarheid van de referenties;

Terwijl de verwerende partij de referenties zorgvuldig moet onderzoeken en de motiveringsplicht moet naleven door in de gunningsbeslissing afdoende te motiveren waarom de referenties opgegeven door PST goSmart bv voldoen aan de besteksvereisten gesteld door de verwerende partij zelf, zodat de in het middel aangehaalde bepalingen en beginselen geschonden zijn.”

De verzoekende partij voert in de toelichting bij het middel aan dat noch het gunningsverslag, noch de beslissing van de raad van bestuur van de verwerende partij enige informatie of motivering bevatten op grond waarvan kan worden verduidelijkt waarom de verwerende partij van oordeel was dat de door de bv PST goSmart ingeroepen referenties voldoen aan de besteksvoorwaarden. Evenmin blijkt dat de referenties zorgvuldig werden onderzocht. Die motiveringsplicht zou des te meer gelden nu de verwerende partij zelf afzonderlijke opdrachten organiseert, enerzijds, voor de eigenlijke boordcomputers/validatoren en, anderzijds, voor de boordcomputer- en/of ticketing-gerelateerde apparatuur. Zij mag er dan ook geenszins van uitgaan dat de referenties voor die onderscheiden opdrachten onderling inwisselbaar zijn.

### *Beoordeling*

12. In de bestreden beslissing van 21 februari 2018 wordt wat de keuze van de offertes betreft, verwezen naar de motivering en het besluit van het gunningsverslag dat gevoegd is bij de bestreden beslissing. In het gunningsverslag wordt het volgende vermeld:

“Iedere inschrijver werd eveneens gecontroleerd of de door hun ingediende offerte voldeed aan de selectie- en minimumvereisten alsook de technische vereisten van het bestek.

Volgens artikel 95 van het KB van 16 juli 2012 dient de aanbestedende overheid zuiver materiële fouten in de offerte te verbeteren.

De offertes van PST goSmart bv en Kapsch CarrierCom Belgium zijn regelmatig en worden weerhouden voor perceel 1.”

Hoewel de motivering van de beslissing tot selectie van de kandidaten voor perceel 1 als eerder summier voorkomt, blijkt toch impliciet uit de voormelde motivering dat de bv PST goSmart voldeed aan de selectievereisten van het bestek, wat impliceert dat de door deze inschrijver voorgelegde referenties geacht werden te voldoen aan het vereiste hieromtrent gesteld in het bestek. Gelet op het feit dat in de huidige stand van het geding wordt aangenomen dat de verwerende partij er op het eerste gezicht terecht mocht van uitgaan dat een referentie voor de installatie van ticketing-apparatuur tevens de montage-onderdelen voor deze ticketing-apparatuur omvat en de betrokken referentie op dat punt dus geen probleem leek te stellen, toont de verzoekende partij niet aan dat de verwerende partij niet mocht volstaan met een summiere motivering waaruit weliswaar impliciet maar toch duidelijk bleek dat de voorgelegde referenties werden geacht te voldoen.

Bovendien, in de mate dat het middel de formele motivering betreft, toont de verzoekende partij op het eerste gezicht niet aan waarom de meegedeelde motieven haar niet in staat stelden terdege te oordelen of het zin heeft zich in rechte te verweren tegen de bestreden beslissing. Het tegendeel blijkt veeleer uit het middel, waarin de verzoekende partij deze motivering uitgebreid betwist door aan te voeren dat de door de bv PST goSmart voorgelegde referenties niet voldoen aan de selectievereisten. Aldus lijkt op dat punt voldaan aan de formelemotiveringsplicht, minstens aan de *ratio legis* ervan.

13. Het tweede middel is niet ernstig.

#### *VII. Besluit en kosten*

14. Geen van de middelen is ernstig gebleken. De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid dient dan ook te worden verworpen.

15. In de gegeven omstandigheden past het de kosten van de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid ten laste te leggen van de verzoekende partij.

Deze kosten bestaan uit het rolrecht, de bijdrage overeenkomstig artikel 5, § 1, van de wet van 19 maart 2017 ‘tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand’ en de door de verwerende partij gevraagde rechtsplegingsvergoeding.

## **BESLISSING**

**1. Het verzoek van de bv PST goSmart tot tussenkomst wordt ingewilligd.**

**2. De Raad van State verwerpt de vordering.**

**3. De verzoekende partij wordt verwezen in de kosten van de vordering, begroot op een rolrecht van 200 euro, een bijdrage van 20 euro en een rechtsplegingsvergoeding van 700 euro, die verschuldigd is aan de verwerende partij.**

**De tussenkomende partij wordt verwezen in de kosten van de tussenkomst, begroot op een rolrecht van 150 euro.**

Dit arrest is uitgesproken te Brussel, in openbare terechtzitting van 29 maart 2018, door de Raad van State, XIIe kamer, samengesteld uit:

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Dierk Verbiest, | kamervoorzitter, |
| bijgestaan door |                  |
| Silja Doms,     | griffier.        |

**De griffier**

**De voorzitter**

**Silja Doms**

**Dierk Verbiest**